

1503269-85.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503269-85.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503269-85.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2347629/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 22082020 - 07º D.P. GUARULHOS, 4052/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2347629 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON COSTA SILVA DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

JEFERSON COSTA SILVA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 21h35min, na Rodovia Presidente Dutra, Macedo, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer, de placas GKD0G27, avaliada em R\$

18.000,00, uma mochila, avaliada em R\$ 50,00, e o telefone celular Xiaomi/Note 9 Pro, avaliado em R\$ 1.000,00, bens de propriedade da vítima Roberto Roberval Marques dos Santos, conforme boletim de ocorrência de fls. 6/9, autos de exibição e apreensão e de entrega de fls. 12 e 13/14, auto de avaliação de fls. 15 e auto de reconhecimento pessoal de fls. 11 (fls. 62/63).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/55).

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 64/65).

O réu foi citado (fls. 71/73) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 81/82).

Em 25 de abril de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 81/82).

Nesta data, na audiência de instrução virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi ouvida a vítima e colhido o depoimento de uma testemunha comuns.

Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição/apreensão (fl. 12), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 13/14), auto de avaliação (fl. 15), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 11), bem como pela prova oral trazida aos autos. Da mesma forma, a autoria criminosa é incontestada e aponta para a participação do acusado, senão, vejamos.

O acusado JEFERSON COSTA SILVA DO NASCIMENTO, em solo policial, desejou utilizar-se do seu direito constitucional de permanecer calado, para se manifestar em juízo.

(fl. 05). Em juízo, confessou parcialmente os fatos, admitindo a subtração da moto, porém negou o uso de arma de fogo, alegando que apenas simulou estar armado. Negou também que seu comparsa estivesse armado como mencionado pela vítima.

A vítima ROBERTO ROBERVAL MARQUES DOS SANTOS, em sede inquisitorial, declarou que, no dia dos fatos, por volta das 21hs35min a caminho do seu trabalho no bairro do Macedo, na condução do seu motociclo Yamaha, de placa GKD-0G27, quando seguia pelas imediações da via Dutra, na pista da esquerda, altura do antigo Poupatempo teve seu motociclo interceptado por outro motociclo da cor azul, salvo engano marca Twister, ocupado por dois indivíduos cujo garupa de arma em punho anunciou o roubo, o revistando em cima da moto, ato contínuo mandou descer e assumiu a direção da moto se evadindo com o comparsa sentido São Paulo; com o motociclo foi subtraído documentos pessoais do declarante e seu telefone celular marca Xiaomi. Desta forma o declarante realizou contato via 190 e após alguns minutos recebeu ligação da PM, a qual informou que sua moto foi localizada e apresentada nesta delegacia; Aqui feito o reconhecimento de pessoas, o declarante reconheceu com certeza e precisão o indiciado Jeferson Costa Silva do Nascimento como sendo o garupa que anunciou o assalto e subtraiu sua moto e seus pertences encontrado pelos policiais na posse do mesmo os quais junto com a moto também foi reconhecido pelo declarante. Os bens recuperados foram restituídos ao declarante em auto próprio. Cabe ressaltar que o motociclo teve danificado os retrovisores e pedal de passagem de marcha e teve o pneu dianteiro estourado, por isso o declarante recebe requisição para submetê-lo na perícia. Declarante informa que seu motociclo custa em torno de 18.000,00, o celular já usado em torno de R\$ 1.000,00 e mochila R\$ 50,00 (fl. 04). Em juízo, relatou que trafegava com sua moto pela Rodovia Presidente Dutra, quando percebeu uma moto com duas pessoas o acompanhando. Foi dar passagem, mas acabou sendo abordado pelo garupa que, portando uma arma, o forçou a estacionar. Disse que o garupa desembarcou da moto, o revistou e além de sua moto subtraiu seu capacete, sua mochila, celular e carteira com documentos. Disse que enquanto era revistado pelo garupa, o condutor da moto estava apontando uma arma, não sabendo dizer se era a mesma arma que inicialmente o garupa usou na abordagem ou uma segunda arma.

Acrescentou que quando foi revistado, o garupa usou as duas mãos para fazer a revista, por isso não sabe se ele guardou a arma na cintura ou repassou a arma para o condutor, porém reafirmou que viu os dois portando arma de fogo. Afirmou, ainda, que enquanto era revista, o garupa, por diversas vezes fez ameaças de morte, falando para o condutor da moto, atirar caso ele se mexesse, pois suspeitava que a vítima fosse policial. Após o garupa sair conduzindo sua moto e levando seus pertences, sendo acompanhado do comparsa. Foi para o trabalho e ligou para o 190, relatando o crime. Menos de 5 minutos a polícia retornou, noticiando a recuperação da moto. Sua moto foi recuperado, porém o pneu foi cortado e a carenagem foi quebrada. Gastou entre R\$2.200,00 e 2.300,00 no conserto. Também recuperou a mochila com o celular. Somente a carteira não foi recuperada. Ficou sabendo que policiais avistaram sua moto e que o condutor não obedeceu a ordem de parada, porém acabou caindo da moto e foi abordado. Pelo que soube sua mochila foi apreendida com o agente. Viu o rapaz deitado na delegacia e o reconheceu como sendo o garupa que o abordou. Disse que na oportunidade o roubador estava de capacete, mas não tinha viseira, então, na delegacia, reconheceu o indivíduo pelo rosto, pelas roupas, que eram as mesmas, e pela voz, pois ouviu ele falando com os policiais. Disse que teve certeza na ocasião. Nessa data, ao ver o réu, que estava acompanhado de outros dois presos, novamente o reconheceu.

As declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“(…) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo”

(Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

“Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado.” (RJTACrim 42/235).

“Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

“Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

Os policiais militares MARCILIO DOS SANTOS COSTA e FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES FERREIRA, na sede extrajudicial, em depoimentos semelhantes, disseram que durante patrulhamento de rotina, com a Vtr. 15385, na região do Taboão, uma viatura informou a rede rádio que estavam acompanhando uma motocicleta, branca, marca Yamaha, placa GKD-0G27 produto de roubo pelas imediações da Rod. Pres. Dutra, ato contínuo, a equipe se deparou com a moto na região da Praça Oito, onde o condutor

desobedeceu a ordem de parada, logo deram início ao acompanhamento do motociclo que se deu por toda extensão da avenida Otávio Braga de Mesquita, terminando na avenida Monteiro Lobato com a rua Mazagão, altura do numeral 6430, em Cumbica, local que o condutor perdeu o controle e caiu no solo se lesionando com escoriações nas mãos e pernas; O condutor identificado por Jeferson Costa Silva do Nascimento, não ofereceu resistência, não foi encontrado em sua posse nenhuma arma de fogo e indagado sobre a origem da moto, confessou que havia "prego" a mesma na Rod. Pres. Dutra, com ele, foi encontrado os pertences da vítima. O indiciado antes de ser aqui conduzido, recebeu atendimento no PA. São João, onde foi medicado e liberado, conforme guia de atendimento apresentada. Nesta delegacia a vítima Roberto Roberval Marques deu detalhes do roubo sofrido instantes antes na rodovia Dutra e aqui reconheceu o indiciado com certeza e precisão como sendo o garupa da moto que anunciou o assalto, como também reconheceu a moto e alguns de seus pertences encontrados na posse do indiciado (fls. 02/03).

Em juízo, o policial militar MARCILIO DOS SANTOS COSTA narrou que recebeu informações de que uma motocicleta não teria obedecido a ordem de parada dada por policiais de uma viatura. Em patrulhamento avistou a moto, que empreendeu fuga por mais de quatro quilômetros, até bater em um ônibus e o condutor cair. Feita a abordagem e questionado sobre o motivo da fuga, o acusado assumiu que teria roubado a moto na Rodovia Pres. Dutra. Na ocasião ainda não tinha conhecimento sobre o roubo da motocicleta. O réu foi levado para atendimento, na delegacia a vítima reconheceu o acusado.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante da confissão do acusado, ainda que parcial, acrescida das declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, dos depoimentos dos policiais, bem como das circunstâncias da prisão do acusado, detido logo após os fatos, em poder do motociclo subtraído e demais pertences da vítima, além dos

reconhecimentos realizados, forçoso reconhecer que restou demonstrada, de forma inequívoca, a participação de JEFERSON na ação criminosa retratada nos autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

Além da certeza da materialidade e da participação do acusado no crime, com igual precisão, o concurso de agentes restou evidente através da forma de atuação do réu, agindo com outro indivíduo não identificado, todos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa, o que importa em reconhecer a causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Seguindo esse entendimento: TACRSP: "Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível" (RJDTACRIM 23/96).

Ainda, nesse tocante, insta frisar que "não apenas aquele que comete ou pratica a ação típica incorre no crime previsto pela norma penal. Esta premissa, enquanto fundamento do concurso de pessoas, decorre justamente da possibilidade de que - pela divisão de tarefas - alguns agentes, apesar de atuarem na atividade ilícita, não realizem nenhum dos núcleos de tipo característicos do injusto culpável". (TJSC - Apelação Criminal n., de Joinville, Rel. Des. Torres Marques, j. em 19/08/2008). No tocante à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, esta também foi suficientemente comprovada, diante das declarações firmes da vítima, dando conta que o acusado e seu comparsa estavam armados na ocasião, sendo irrelevante o fato da arma não ter sido apreendida, a té porque pode ter sido dispensada pelo réu durante a fuga da polícia, bem como poderia ter ficado em poder do comparsa, segundo dinâmica do crime relatada pela vítima. Assim, nessa esteira, urge reconhecer a circunstância majorante estabelecida no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, inserida no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.654/18, que revogou o inciso I do §2º daquele dispositivo legal.

Sobre a desnecessidade da apreensão da arma utilizada no evento criminoso, bem como a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, para o reconhecimento da agravante em questão, a jurisprudência vêm reiteradamente decidindo:

"Roubo majorado Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Ausência de fragilidade probatória - Condenação mantida. Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Fração de três oitavos em razão da presença de duas causas de aumento - Possibilidade - Maior reprovabilidade da conduta. Regime semiaberto - Impossibilidade - Reincidência e gravidade concreta do delito que impõem a manutenção do regime fechado - Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0006588-14.2016.8.26.0050; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Grifei);

"Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Causas de aumento bem caracterizadas. Arma de fogo. Apreensão. Desnecessidade. Palavra da vítima. Pena bem aplicada. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1522520-11.2019.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020) (Grifei);

"Roubo qualificado Palavra das vítimas Reconhecimentos na delegacia confirmados em juízo Negativa do réu isolada nos autos Condenação mantida; Roubo qualificado Crime cometido antes da edição da Lei nº 13.654/2018, na vigência da redação anterior do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal Emprego de arma de fogo Falta de apreensão e perícia Irrelevância Prova oral indicando a utilização do objeto Qualificadora

reconhecida Precedentes; Roubo qualificado Aumento da pena base Réu primário Crimes que não ultrapassaram a conduta esperada Ação que patrimônio de duas vítimas Crime único Impossibilidade Regime fechado Cabimento Recurso da Defesa improvido, com acolhimento parcial daquele apresentado pelo Ministério Público". (TJSP; Apelação Criminal 1502893-38.2017.8.26.0536; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020) (Grifei);

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. ROUBO. EXTORSÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. Concluindo as instâncias ordinárias pela efetiva prática do delito de extorsão, o acolhimento de tese que pretende alcançar conclusão contrária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente. 4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar-lhe provimento (STJ; AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.557.476 - SP (2019/0237110-8); Relator Ministro Nefi Cordeiro; Órgão Julgador: Sexta Turma; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020) (Grifei);

"A não apreensão da arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não é motivo suficiente para afastar a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I do Código Penal, mormente se a vítima afirma categoricamente que um dos agentes portava um revólver" (Apelação Criminal nº 906.377.3/6, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. IVAN MARQUES, j. em 25/05/2006);

"Inafastável, pois, o decreto condenatório, e improcedente a tese invocada para atentar-se o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma. A lei processual não exige a apreensão da arma para caracterização da majorante prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do CP, que pode ser demonstrada por qualquer meio de prova jurisprudencial (JUTACrim 89/443, 93/3.778; RT 672/379). E, no caso, o emprego de arma resultou seguramente demonstrado pelas declarações idôneas de ambas as vítimas" (TACRIM- SP- AC- Rel. Renê Ricupero - j.18.11.1197- IBCCrIm 63/234);

"O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - RJD 10/142);

"ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - apreensão e exame pericial do instrumento para reconhecimento da qualificadora - Desnecessidade - Comprovação do uso pela vítima - Suficiência: Em sede de roubo qualificado é desnecessária a apreensão e periciamento da arma utilizada para o reconhecimento da qualificadora correspondente, desde que o uso do instrumento seja comprovado pela vítima" (Apelação nº 1.158.879/2 - São Paulo - 9ª Câmara - Relator: Ferreira Rodrigues - 12/1/2000 - v.u. - voto 7.198);

"ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Localização ou apreensão da arma para o reconhecimento da qualificadora - Desnecessidade - intimidação da vítima - Suficiência:- É irrelevante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art.

157, § 2º, I, do CP, que a arma não seja localizada ou apreendida, pois razão da majorante é a intimidação da vítima” (Apelação nº 1.185.391/8 - São Paulo - 16ª Câmara - Relator: Ubiratan de Arruda - 10/02/2000 - V.U. Voto nº 4.249).

Noutro vértice, é de se salientar que, embora presentes duas causas especiais de aumento de pena, quais sejam, concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), que fixa o aumento entre 1/3 até 1/2, e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), que autoriza aumento de 2/3, implementada pela Lei n.º 13.654/18, já vigente à época dos fatos, entendo que no caso em apreço, apenas o aumento de 2/3 (dois terços), o maior deles, previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, deve prevalecer na terceira fase de aplicação da pena, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que prevê que diante de mais de uma causa de aumento, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo o de maior valor.

É verdade que o artigo 68 em análise usa a palavra “pode”, o que permite a aplicação das três majorantes cumulativamente. Todavia, a meu ver, apenas em casos específicos se justificaria tal cumulação, devidamente fundamentada em fatos concretos, a fim de evitar uma desproporcionalidade das penas, o que não entendo que seja o caso dos autos.

Desta feita, no presente caso, deve prevalecer na terceira fase de aplicação da pena a majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, devendo o concurso de agentes ser considerado na primeira fase de aplicação da pena, como circunstâncias judicial desfavorável.

O crime se consumou, uma vez que no caso de roubo a consumação se dá com o emprego de violência ou de grave ameaça e a subtração do bem, não sendo necessária a posse mansa e passiva da res furtiva. No caso dos autos, o réu foi abordado em local diverso dos fatos, em poder dos bens subtraídos da vítima, após os fatos, por policiais que sequer presenciaram a prática delitativa, mas apenas tomaram conhecimento do crime após a sua consumação, o que torna inquestionável a consumação delitativa, atéw orque apenas parte da res foi recuperada.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4. [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega Provimento” (STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014).

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitativa, bem como estando caracterizada a culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, na primeira fase, considerando as circunstâncias do crime, verifico que a ação criminosa foi praticada em concurso com outro sujeito desconhecido, conduta mais grave por diminuir a possibilidade de reação da vítima e aumentar a capacidade de intimidação dos agentes, caracterizando causa de aumento do §2º, II, do artigo 157 do Código Penal que, no entanto, deverá ser considerada neste momento, como circunstância judicial, pelas razões já expostas na fundamentação, haja vista que nenhuma circunstância pode ficar à margem da análise do juízo. Ademais, também deve ser considerada nessa fase a natureza e valor dos bens subtraídos (motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer, avaliada em R\$ 18.000,00, uma mochila, avaliada em R\$ 50,00, e o telefone celular Xiaomi/Note 9 Pro, avaliado em R\$ 1.000,00), que torna a conduta mais reprovável, bem como as consequências acarretadas às vítimas em razão da ação delituosa. Ademais, observo, ainda, que o réu praticou o presente crime quando em cumprimento de pena em regime aberto (processo nº 0002420-32.2017.8.26.0535, da 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - fls. 28/30), o que demonstra maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, evidenciando ainda descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprido salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena em regime aberto. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do *ne bis in idem*, até porque o que se busca é aplicar o princípio da individualização da pena. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em *ne bis in idem* com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Desta feita, de acordo com as circunstâncias judiciais desabonadoras apontadas, acresço a pena-base de 1/4 (um quarto), fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes a serem observadas, até porque o réu confessou parcialmente os fatos, negado o emprego de arma de fogo, com o nítida intenção de minimizar sua responsabilidade criminal, o que afasta a atenuante da confissão. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos, pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 0002420-32.2017.8.26.0535, da 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0013376-03.2018.8.26.0041, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 28/30 e F.A. de fls. 103/108 e fls. 109/114), sendo, portanto, reincidente. Assim, exaspero as penas aplicadas em 1/6 (um sexto), fixando-as em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição de pena. Entretanto, foram devidamente caracterizadas as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previstas no inciso II do § 2º e no inciso I do

§ 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, devendo prevalecer a causa de aumento maior, pelas razões já expostas. Assim, nessa terceira fase, aumento as penas em 2/3 (dois terços), fixando-as, em definitivo, em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade de pena imposta e a ocorrência de grave ameaça a pessoa (art. 44, I, do CP), impossível a concessão do "sursis" ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO.

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, além do fato do réu ser reincidente e ter praticado o crime quando cumpria pena em regime aberto, o que evidencia que faz do crime seu meio de vida, bem como que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito, sendo inadequado regime menos rigoroso. Ademais, considerado a quantidade da pena aplicada é esse o regime legal.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

"Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (Apelação nº 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

"Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório. Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie, e foi fixado nos termos da Lei. Apelo não provido. (Apelação nº 90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu ROBERTY, o regime de pena imposto por lei, o fato de ser reincidente, além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, as condições subjetivas do acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a

própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituesa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitativa e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR JEFERSON COSTA SILVA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, ao cumprimento de 9 (NOVE) ANOS, 8 (OITO) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente FECHADO, e ao pagamento de 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O acusado não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 13 de junho de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA